

Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão **16/4/2025**

Cautelares em Procedimentos de Contratação – **Referendo e Julgamento**

M-002: TC-005870.989.25-8
Representante: Maria Idalina Tamassia Betoni
Representada: Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara
Responsável: Wilian José de Oliveira Meana, Prefeito Municipal
Assunto: Edital do Pregão Presencial nº 1/2025, cujo objeto é a prestação de serviços médicos, sendo ambulatoriais de especialidades, serviços de plantões médicos diurno e noturno, bem como de retaguarda médica 24 horas para necessidade emergencial, tendo em vista a necessidade de prestar assistência médica à população, pelo período de 12 meses.

Valor Total Estimado: R\$ 2.687.350,08

Advogados cadastrados no e-TCESP: Maria Idalina Tamassia Betoni (OAB/SP 264.559).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. INCOMPATIBILIDADE ENTRE O OBJETO E A PARTICIPAÇÃO DE COOPERATIVAS NO CERTAME. PROCEDENTE.

Relatório

Trata-se de representação intentada por Maria Idalina Tamassia Betoni contra o edital do Pregão Presencial nº 1/2025 da Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a prestação de serviços médicos, sendo ambulatoriais de especialidades, serviços de plantões médicos diurno e noturno, bem como de retaguarda médica 24 horas para necessidade emergencial, tendo em vista a necessidade de prestar assistência médica à população, pelo período de 12 meses.

Em suma, insurgiu-se a Representante contra os subitens 1.3.1 e 1.3.2 do edital, cujos termos são os seguintes: “1.3.1 A participação de profissionais organizados sob a forma de cooperativa fica condicionada ao cumprimento dos requisitos

estabelecidos no artigo 16 da Lei número 14.133/2021. 1.3.2 Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa deverão apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados”.

Sustenta haver incompatibilidade entre o objeto licitado e a admissão de cooperativas no certame.

É nesses termos que requereu a sustação cautelar do procedimento e a retificação do ato convocatório.

O edital é datado de 20/1/2025 e a sessão pública estava designada para a data de 24/3/2025.

Por decisão de 21/3/2025 publicada no DOE-TCESP de 24/3/2025, foi requisitada cópia do edital para o exame nos termos dos arts. 170, § 4º, e 171, §§ 1º e 3º da Lei Federal nº 14.133/21, bem como foi determinada a sustação cautelar do procedimento e fixado prazo de 10 dias úteis para cumprimento e apresentação de justificativas e esclarecimentos.

Em resposta, a Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara alegou que *“com relação à participação ou não de Cooperativas, de fato essa Administração optou por prever a participação em atendimento ao art. 16 da Lei 14.133/2021, contudo, diante do entendimento deste Egrégio Tribunal, a Administração aguarda decisão para prosseguimento e Retificação de edital”.*

A Assessoria Técnica e o Ministério Público de Contas manifestaram-se pela procedência da representação.

É o relato do necessário.

npg

Voto

TC-005870.989.25-8

Preliminarmente, submeto ao referendo deste e. Plenário decisão em que foi determinada a sustação cautelar do Pregão Presencial nº 1/2025 da Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é a prestação de serviços médicos.

No mérito, procede a representação.

Há tempos se estabeleceu neste Tribunal o entendimento de que é incompatível a participação de cooperativas em licitações para a prestação de serviços cujo escopo de interesse público a ser alcançado demande a presença de elementos como a relação de subordinação, a pessoalidade e a habitualidade, o que levou à edição da Deliberação SEI 17044/2021-10 publicada em 15/12/2022:

“Inexiste amparo legal para a participação de Cooperativas de Trabalho em procedimentos licitatórios voltados à contratação de serviços que, pela real natureza da relação a ser estabelecida, demandem subjacente vínculo de subordinação e dependência, bem como pessoalidade e habitualidade.”

Destaco que permanece íntegra tal Deliberação sob a vigência da Nova Lei de Licitações, porquanto os estudos para se chegar a esse comando já levaram em consideração o art. 16 da Lei 14.133/2021¹. E não poderia ser diferente, pois o caráter das relações estabelecidas remanesce o mesmo, seja na Lei anterior, seja na Lei 14.133/2021.

E tal relação de subordinação e dependência, bem como pessoalidade e habitualidade estão presentes no ajuste de serviços médicos que aqui se pretende.

¹ “[...] **Considerando** o disposto no artigo 16 da Lei Federal nº 14.133/21, que define regras e diretrizes para a participação de profissionais organizados sob a forma de cooperativa em licitações públicas; [...]”.

Como estabelece o art. 197² da Carta Magna, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, aí incluídas as ações e serviços de forma complementar nos termos do § 1º do art. 199 da CF, “***cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle [...]***” (negrito acrescido).

E há ainda os arts. 8º e 9º³ da Lei 8.080/90, segundo os quais: - as ações e serviços de saúde, executados diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente; e - a direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, sendo exercida em cada esfera de governo.

Ora, se é atribuído ao Poder Público a regulamentação, fiscalização e controle de ações e serviços públicos de saúde, daí se extrai a subordinação da entidade privada contratada às cláusulas contratuais impostas pelo Poder Público e às diretrizes do seu sistema regulatório e de fiscalização; de maneira que não há como conformar tais comandos com os conceitos de autonomia e autogestão inerentes às cooperativas, conforme se pode extrair dos §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei 12.690/2012: “a ***autonomia [...]*** deve ser exercida de forma coletiva e coordenada, mediante a fixação, em Assembleia Geral, das regras de funcionamento da cooperativa e da ***forma de execução dos trabalhos [...]*** considera-se ***autogestão o processo democrático no qual a Assembleia Geral define as diretrizes para o funcionamento e as operações da cooperativa, e os sócios decidem sobre a forma de execução dos trabalhos, nos termos da lei***” (negrito acrescido).

² “Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”

³ “Art. 8º As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

Art. 9º A direção do Sistema Único de Saúde (SUS) é única, de acordo com o inciso I do art. 198 da Constituição Federal, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seguintes órgãos: [...].”

Há ainda outro aspecto de tais relações que se pode extrair, por exemplo, do seguinte excerto de interesse de julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, cujos termos entendo remanescer mesmo sob o regime da Lei 14.133/2021:

“Consoante pacífica jurisprudência deste Tribunal, ‘estando comprovado que a licitação visa à contratação de mão de obra para prestação de serviços não eventuais e em caráter de subordinação, a participação de cooperativas no certame implicaria violação à legislação trabalhista, a leis que regem a atividade cooperativa, e à própria Lei 8666/93, que diz ser vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar no edital condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do certame (Ag.n. 2003.01.00.023353-0/DF, Rel. Des. Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues)”

(TRF-1ª Região, 2ª T. Suplementar, Apelação Cível nº 2004.34.00.022894-6/DF, Rel. Osmane Antonio dos Santos, j. 2/7/2013 apud Evelise Pedroso Teixeira Prado Vieira, Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública Comentada – Doutrina e Jurisprudência, 2ª ed. São Paulo: Ed. Verbatim, 2014, pp.: 102)

Por todos esses aspectos é que remanescem aplicáveis à presente matéria todos os precedentes deste Tribunal que levam ao entendimento da incompatibilidade da participação de cooperativas em licitações destinadas à contratação de serviços médicos de maneira suplementar ao sistema local de saúde. Veja os excertos abaixo, que também trataram de licitações para contratar serviços médicos:

“[...] Afora estes pontos, todavia, interpretação apropriada do ordenamento desvela a procedência das demais insurgências ventiladas na inicial. A começar pela possibilidade de participação de Cooperativas de Trabalhadores, descrita no item 5.3.1.

Segundo debates que findaram com a edição da Deliberação SEI nº 0017044/2021-10, inexistente amparo legal para a participação de cooperativas de trabalho em procedimentos licitatórios voltados à contratação de serviços que, pela real natureza da relação a ser estabelecida, demandem subjacente vínculo de subordinação e dependência, bem como pessoalidade e habitualidade.

Sob essa ótica, a fim de evitar prática ilícita de intermediação de mão de obra, com afronta aos direitos sociais e previdenciários, profusa jurisprudência censura a participação de cooperativas e associações sem fins lucrativos em licitações públicas destinadas especificamente à prestação de serviços médicos.

E assim o não só em razão da incompatibilidade dos misteres com o regime aplicável a tais organizações ou pelo tratamento tributário privilegiado que lhes é próprio, mas pela subversão de princípios

substanciais do cooperativismo e da disciplina de complementaridade estabelecida na Lei Federal nº 8.080/90 [...]”.

(Tribunal Pleno, TC-6688.989.23-5, Rel. Cons. Edgard Camargo Rodrigues, j. 12/4/2023, DOE de 26/4/2023)

“Conforme assinalado em juízo preliminar, a jurisprudência desta E. Corte tem decidido no sentido da impossibilidade da participação de sociedades cooperativas e associações civis, tendo em vista a incompatibilidade do regime jurídico dessas entidades com o exercício da atividade empresarial da prestação dos serviços médicos.

Afinal, não só tratamento fiscal mais favorável às cooperativas e associações civis tem força para comprometer a igualdade de oportunidades entre eventuais interessados no procedimento licitatório, mas também o modo de execução da obrigação, sobretudo na ausência do vínculo profissional ou de relação de emprego, não se compatibiliza com a forma ordinária de contratação de prestadores de serviço por parte do Poder Público, na forma da legislação aplicável (Lei nº 10.520/02 e Lei nº 8.666/93).”

(Tribunal Pleno, TC-24/11/2021, Rel. Cons. Renato Martins Costa, j. 24/11/2021, DOE de 3/2/2022).

Ante o exposto, voto pela **procedência** da representação, com **determinação** à Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara para que: **(a)** exclua os subitens 1.3.1 e 1.3.2 do edital; **(b)** passe a vedar a participação de cooperativas; e **(c)** revise o edital para o fim de retificar eventuais cláusulas que porventura contenham disposições que acatem a participação de cooperativas.

A Administração deverá republicar o edital retificado nos termos do art. 55, § 1º, da Lei 14.133/2021, cessando-se desde já os efeitos da medida cautelar inicialmente decretada.

Acolhido este entendimento pelo e. Plenário, deverá ser intimada a Prefeitura Municipal de Águas de Santa Bárbara, na forma regimental.